

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0096976-60.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JAILTON SOUZA SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erika Soares de Azevedo Mascarenhas****V I S T O S .**

JAILTON SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 07:00 horas, na Avenida Manoel Bandeira, altura no nº 100, no bairro Vila Leopoldina, nesta capital, trazia consigo para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 927 (novecentos e vinte e sete) "eppendorfs" de cocaína, pesando 756,4g, substância química que causa dependência física e psíquica.

O acusado, notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensor Público nomeado nos autos.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado, sendo então designada audiência concentrada de instrução e julgamento. Foram ouvidas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Subsidiariamente, requereu (I) fixação da pena base no mínimo legal; (II) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (III) aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06; (IV) fixação do regime aberto para cumprimento de pena; (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (VI) direito de recorrer em liberdade.

**É o relatório.
D E C I D O.**

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/09, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/13, pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico encartado a fls. 135/137, que resultou positivo para *cocaína*, bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado negou a prática do crime (fls. 09).

Em juízo, já sob o crivo do contraditório, da mesma forma, apresentou singela negativa de autoria.

Alegou que estava caminhando na via pública, na direção de uma padaria para comprar pão, quando se deparou com os policiais tentando abordar um indivíduo que traficava no local.

Contou que, o traficante conseguiu

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

fugir e por essa razão foi abordado.

Em razão de ter outro envolvimento criminal, os milicianos foram até a viatura, de onde retiraram as drogas, e, assim, passaram a responsabilizá-lo pelos entorpecentes apreendidos.

Mas essa versão, além de previsível e bem pouco consistente, restou isolada nos autos, e veio desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa – notadamente o firme relato das testemunhas policiais, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, comprometendo sobremaneira o réu.

É que os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Narraram, em uníssono, de forma bastante serena e insuspeita, que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda e consumo de entorpecentes, quando se depararam com o acusado, que ao avistar a viatura, empreendeu fuga.

Em virtude da duvidosa postura do acusado, acharam por bem abordá-lo e verificaram que ele portava uma mochila.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, em busca na mochila que ele carregava, lograram êxito em encontrar vultosa quantidade de cocaína.

Perguntaram-no acerca das substâncias que ele portava, e o acusado, informalmente e visivelmente alterado pelo uso de entorpecente, admitiu que estava praticando o comércio espúrio naquela região.

Assim, deram voz de prisão ao réu e conduziram-no ao Distrito Policial.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

delito, sendo incontroversa a autoria.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado ofereceu pífia e genérica versão exculpatória.

Em Juízo, no mesmo sentido, apresentou singela negativa de autoria, cuja veracidade nem de longe comprovou, como lhe competia, nos termos do que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim é que tentou fazer crer que policiais o abordaram e, deliberadamente, passaram a acusá-lo injustamente pela prática de tráfico de drogas, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para tanto.

Todavia, essa versão se mostrou bastante pueril, previsível e inconsistente. Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais com o exclusivo objetivo de incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.

Não parece mesmo crível.

No caso em apreço, o réu foi surpreendido enquanto trazia consigo considerável quantidade de droga, separada por 927 invólucros plásticos contendo cocaína, prontos para o comércio, não apresentando justificativa convincente quando instado, restando evidente que estava no local realizando o comércio espúrio.

No mais, os policiais inquiridos, de forma serena, deram conta da diligência que realizaram e que culminou com a abordagem e apreensão, em poder do réu, de todo o material ilícito descrito na inicial acusatória.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: ***“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”***.(TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

O acusado foi visto por policiais, que realizavam patrulhamento de rotina no local, quando saiu correndo ao avistar a viatura. Perceberam que o réu portava uma mochila e, nesse momento, fizeram a abordagem e localizaram os *ependorfs* de cocaína.

A alegação do acusado, no sentido de que estava somente a caminho da padaria e que os policiais, por não terem logrado êxito em prender o verdadeiro traficante, passaram a incriminá-lo deliberadamente, não convenceu, até porque os policiais foram categóricos quando narraram que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura, já carregando a mochila que continha as drogas apreendidas.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como os tóxicos estavam acondicionados – **927 invólucros plásticos contendo cocaína** - e as circunstâncias da prisão afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei especial.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: ***“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização”*** (TJSP – AC 9.751-3 – Rel. Gonçalves Sobrinho – RJTJSP 75/343).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente – Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização – Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível – Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT – AC 565/86 – Rel. Mauro José Pereira – RT 620/331).

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão de desclassificação do delito, pleiteada pela Defesa.

Logo, comprovado o desiderato de mercancia, incontroversa a responsabilidade do réu pela droga, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão encartada as fls. 144 dá conta de uma condenação definitiva suportada pelo réu, perante a 17ª Vara Criminal da Capital, por decisão que transitou em julgado para a defesa em 17 de julho de 2015 e será considerada para fins de reincidência.

O artigo 42 da Lei 11.343/06, que prepondera sobre critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, determina que, na fixação das penas, deverão ser consideradas a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. Logo, pela quantidade expressiva de cocaína encontrada em poder do acusado, já separada por inúmeras porções individuais, ou seja, 927, o que revela intensidade do dolo, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, seis anos de reclusão e seiscentos dias multa.

Não há que se falar em confissão espontânea, tendo em vista que a versão apresentada pelo réu não retratou a verdade real dos fatos, até porque ele negou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a responsabilidade pelo tóxico apreendido.

Pela reincidência comprovada, agravo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em sete anos de reclusão e setecentos dias multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Pelas razões consignadas quando da fixação da pena base e ainda pela comprovada reincidência, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção na dosimetria da pena por conta da reincidência.

Nesse sentido: **"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.**

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade. Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido." (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE))

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **JAILTON SOUZA SANTOS**, R.G. nº 36.075.851, e o condeno ao cumprimento sete anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a setecentos dias multa, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da lei 8.072/90.

Tendo em vista a gravidade do crime, considerado hediondo, e pela comprovada reincidência, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e igualmente não preenche os requisitos do artigo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2017

ÉRIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**